

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0084075-60.2016.8.26.0050**
 Classe - Assunto: **Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS**
 Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Erika Soares de Azevedo Mascarenhas**

V I S T O S.

WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 06 de outubro de 2016, por volta das 13:05 horas, na Avenida Dona Belmira Marin, nº 2542, no bairro Grajaú, nesta capital, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 (vinte e sete) eppendorfs de cocaína, pesando 9,7g e 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos contendo maconha, pesando 38,7g.

O acusado, notificado nos termos do que dispõe o artigo 55 da Lei nº 11.343/2006, apresentou Defesa Prévia, subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos.

Recebida a denúncia, o acusado foi citado, sendo então designada audiência concentrada de instrução e julgamento. Foram ouvidas as testemunhas arroladas, interrogando-se ao final o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária.

É o relatório.**D E C I D O.**

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do delito veio comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 05/09, pelo boletim de ocorrência de fls. 11/13, pelo auto de



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

exibição e apreensão de fls. 14/15, pelo laudo pericial de exame químico-toxicológico encartado a fls. 97/99, que resultou positivo para *cocaína* e *tetrahydrocannabinol*, bem como pela prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado negou a autoria delitiva.

Declarou que não estava traficando no local e que, na verdade, é usuário de entorpecentes.

Em juízo, já sob o crivo do contraditório, da mesma forma, pôs-se a negar a prática delituosa, alterando a versão anteriormente apresentada.

Alegou que reside próximo ao local dos fatos e que em outras oportunidades já havia sido abordado pelos mesmos policiais.

Disse que voltava de um ferro velho, foi ao local para comprar drogas e foi abordado por policiais.

Por fim, contou que outros indivíduos foram abordados, dentre eles o traficante, e conduzidos ao Distrito, no entanto, não declinou suas respectivas qualificações.

Mas essa versão, além de previsível e bem pouco consistente, restou isolada nos autos, e veio desacompanhada de qualquer demonstração probatória de veracidade, sendo refutada cabalmente pela prova adversa – notadamente o firme relato das testemunhas policiais, sem olvidar das incriminadoras circunstâncias da prisão em flagrante que realizaram -, comprometendo sobremaneira o réu.

É que os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versões coerentes e harmônicas a respeito dos fatos.

Narraram, em uníssono, de forma bastante serena e insuspeita, que realizavam patrulhamento



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

de rotina pelo local dos fatos, que é conhecido como ponto de venda de entorpecentes, quando suspeitaram do acusado.

Esclareceram que o réu, ao avistar a guarnição policial, demonstrou nervosismo exacerbado e tentou empreender fuga.

Assim, acharam por bem realizar a abordagem e, em revista pessoal, deram conta de localizar uma sacola plástica na cintura do acusado.

Procederam a busca no interior desta sacola e, ato contínuo, localizaram as drogas descritas na denúncia.

Acrescentaram que, informalmente, o acusado admitiu que estaria praticando o comércio ilícito naquele local.

Assim, deram voz de prisão ao réu e conduziram-no ao Distrito Policial.

Como consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência do delito, sendo incontroversa a autoria.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o acusado ofereceu pífia versão exculpatória.

Em Juízo, da mesma forma, apresentou singela negativa de autoria, cuja veracidade nem de longe comprovou, como lhe competia, nos termos do que estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim é que tentou fazer crer que estava apenas naquele local para adquirir entorpecentes, uma vez que é usuário de drogas e, ainda, que já teria sido abordado pelos mesmos policiais em ocasião diversa.

Todavia, essa versão se mostrou bastante pueril, previsível e inconsistente. Aliás, acatar a falaciosa fala do réu implicaria reconhecer que houve verdadeiro conluio criminoso engendrado pelos policiais com o exclusivo objetivo de incriminar injustamente pessoa que sequer conheciam.

Não parece mesmo crível.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
6ª VARA CRIMINAL
AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

No caso em apreço, o réu foi surpreendido no local dos fatos, se portou de forma a provocar suspeitas, o que motivou a abordagem. Ao avistar os milicianos, se assustou e tentou empreender fuga. Quando revistado, policiais localizaram em sua cintura 27 *eppendorfs* de cocaína e 25 invólucros plásticos contendo maconha, todos no interior de uma sacola plástica que portava. A droga estava separada, pronta para o comércio e, quando instado, informalmente, o acusado admitiu a imputação.

No mais, os policiais inquiridos, de forma serena, deram conta da diligência que realizaram e que culminou com a abordagem e apreensão, em poder do réu, de todo o material ilícito relacionado na inicial acusatória.

E os esclarecimentos apresentados pelos policiais, é sempre bom consignar, são dignos de toda credibilidade, sobretudo não existindo demonstração probatória de qualquer interesse deles em prejudicar pessoa inocente.

Como qualquer testemunha, os policias prestam compromisso de dizer a verdade, e a versão que apresentaram só pode ser desprezada se existir prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos, o que evidentemente não ocorre no caso em tela.

Nesse sentido: ***“Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas”***. (TJRJ – AC – Rel Synésio de Aquino – RDTJR 7/287).

A alegação o réu, no sentido de que é apenas usuário de entorpecentes, que teria se dirigido local para adquiri-los, e, ainda, que os policias já o conheciam, não convenceu, até porque ele foi preso em flagrante, enquanto estava na posse de toda a droga, além de, informalmente, admitir a prática delituosa.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Quanto ao tóxico apreendido, desnecessário maiores digressões acerca de sua destinação. O desiderato de mercancia é manifesto e as circunstâncias da apreensão não deixam margem para dúvidas.

A forma como os tóxicos estavam acondicionados – **27 eppendorfs de cocaína, pesando 9,7g e 25 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 38,7g** - e as circunstâncias da prisão afastam qualquer dúvida quanto à sua finalidade, de forma que não há que se falar em desclassificação do crime para o previsto no artigo 28 da Lei especial.

Assim não fosse, consigne-se que a situação de usuário de drogas não exclui a de traficante, uma vez que: ***“Ainda que se trate de réu viciado no uso de tóxico, a apreensão de grande quantidade da erva em seu poder, revela o objetivo de sua comercialização”*** (TJSP – AC 9.751-3 – Rel. Gonçalves Sobrinho – RJTJSP 75/343).

“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade” (TJSP – HC 42.229-3 – Rel. Onei Raphael – RJTJSP 101/498).

“Tráfico de entorpecente – Grande quantidade de droga apreendida em poder do acusado, evidenciadora do propósito de comercialização – Desclassificação para uso, em razão dependência, inadmissível – Inteligência dos arts. 12 e 16 da Lei 6.368/76.” (TJMT – AC 565/86 – Rel. Mauro José Pereira – RT 620/331).

Por esses argumentos, não há que se falar em prova precária.

Logo, comprovado o desiderato de mercancia, incontroversa a responsabilidade do réu pela droga, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

A certidão encartada as fls. 127 dá conta de uma condenação definitiva suportada pelo réu



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

perante a 24ª Vara Criminal da Capital, que transitou em julgado para a defesa em 04 de fevereiro de 2014 e teve sua pena extinta pelo cumprimento aos 22 de novembro de 2014, que será considerada para fins de reincidência.

Logo, pelos critérios norteadores do artigo 42 da Lei 11.343/06, bem como do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em seu mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e quinhentos dias multa.

Pela reincidência comprovada (certidão de fls. 127), agravo a pena em 1/6 e tornando-a definitiva em cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento de quinhentos e oitenta e três dias multa, fixada a unidade em seu mínimo legal.

Em se tratando de réu reincidente, não estão presentes os requisitos do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06.

E não existe a desproporção no que diz respeito a dosimetria da pena, por conta da reincidência.

Nesse sentido: **"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. POSSE OU PORTE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PRÓPRIO. REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. REINCIDÊNCIA VALORADA COMO CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE E PARA IMPEDIR A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.**

- Este Superior Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, tem amoldado o cabimento do remédio heróico, adotando orientação no sentido de não mais admitir habeas corpus substitutivo de recurso ordinário/especial. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, sobretudo o do devido processo legal e da ampla defesa, tem-se analisado as questões suscitadas na exordial a fim de se verificar a existência de constrangimento ilegal para, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

- Na hipótese sub exame, configurada a reincidência, posto persistente a tipificação do delito de posse para uso próprio, bem como não existe a necessidade que a condenação definitiva pelo delito anterior seja privativa de liberdade. Precedentes.

- Possível a considerar a reincidência como circunstância agravante na segunda fase de dosimetria da pena, bem como para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. [33](#), [§ 4º](#), da Lei n. [11.343/2006](#), sem que se configure bis in idem, pois tal instituto possui finalidade jurídico-legal distinta em cada etapa de aplicação da pena, conforme expressa previsão legal.

- O Supremo Tribunal Federal, em 27.6.2012, por ocasião do julgamento do HC 111.840/ES, declarou a inconstitucionalidade da obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e os a ele equiparados. Assim, a identificação do regime inicial mais adequado à repressão e prevenção dos delitos deve observar os critérios do art. [33](#), [§§ 2º](#) e [3º](#) do [Código Penal](#), bem como do art. [42](#) da Lei [11.343/2006](#), quando se tratar de delitos previstos nessa Lei.

- No caso, apesar de a pena ter sido fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a gravidade concreta do delito, evidenciada pela natureza e diversidade das drogas apreendidas - 26 porções de crack e 1 (um) invólucro plástico de cocaína, (sabe-se que o crack é uma substância que possui um alto efeito devastador, devendo-se impor um maior rigor na apreciação da conduta do paciente) - , e a reincidência da paciente, justificam a imposição do regime inicial fechado, bem como a não substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos do art. [44](#), inciso [III](#), do [Código Penal](#). Habeas corpus não conhecido.". (HC 236982 SP 2012/0058827-2 Relatora: Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE)).

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE** a presente ação penal que a Justiça Pública move contra **WELLINGTON CAVALCANTI DOS SANTOS**, R.G. nº 61.788.432, e o condeno ao cumprimento de **cinco anos e dez meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a quinhentos e oitenta e três dias multa**, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

A pena privativa de liberdade deverá



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

6ª VARA CRIMINAL

AVENIDA DOUTOR ABRAAO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ser cumprida inicialmente no regime fechado, tendo em vista o que dispõe a Lei 11.464/07, que alterou a redação original do artigo 2º, §1º da lei 8.072/90.

Em razão da gravidade do crime, considerado hediondo, e pela comprovada reincidência, para garantia da ordem pública o acusado não poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra, e, igualmente, não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, que não tem aplicação ao crime tratado na presente ação penal, que tem regras especiais e que são aplicadas em detrimento das gerais.

É certo que o réu está preso desde 06 de outubro de 2016, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea "b", da lei 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nesse sentido: ***"Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira obliqua, de verdadeira e inoportuna progressão"*** (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de junho de 2017

ÉRIKA SOARES DE AZEVEDO MASCARENHAS
Juíza de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**